

Cuaderno de cátedra

TEORIA DE LAS NORMAS

Juan Manuel Salgado

INTRODUCCION

El presente trabajo se plantea como una guía de estudio de los puntos 1, 2 y 3 de la unidad II del programa de la materia. No tiene como finalidad suplantar la lectura de la restante bibliografía indicada por la cátedra sino facilitar su acercamiento y comprensión. Este auxilio se considera conveniente puesto que parte de la bibliografía presupone que el lector domina ciertas nociones que no siempre son adquiridas en la enseñanza secundaria. En consecuencia una de las finalidades de esta guía es la de esbozar una síntesis de estas nociones e indicar una bibliografía básica sobre el tema para quienes adviertan la necesidad de su profundización.

Otro motivo por el cual este trabajo puede ser útil a los estudiantes es la focalización de los temas desarrollados en la bibliografía de acuerdo al programa de la materia. Esta función aparece conveniente al advertirse no sólo que los textos no reproducen el orden del programa sino que incluso los objetivos pedagógicos pueden ser diferentes, lo que hace que la importancia que se concede a ciertos temas en la bibliografía no concuerde con la que resulta de articularlos en el contenido general de la materia. Todo programa de estudios contiene necesariamente un recorte del campo a desarrollar. A algunos temas se los considera fundamentales y se les otorga prioritaria atención. Otros son mencionados para indicar su existencia y señalar que algunas profundizaciones o matices no tenidos centralmente en cuenta pueden adquirir importancia. Por último, hay aspectos que se indican de modo marginal o directamente se excluyen al considerarse que su tratamiento constituiría una desviación del hilo expositivo y podría contribuir a confundir los ejes centrales que el desarrollo de la materia trata de dejar claros. Ningún programa de cátedra puede pretender agotar el campo de la materia que da. Siempre es necesario focalizar los aspectos que se consideran centrales y atender a ellos descuidando otros que se juzgan secundarios, de acuerdo a los objetivos pedagógicos propuestos. Cuando, como en este caso, la bibliografía coincide sólo parcialmente con los objetivos y desarrollo del programa de la materia, se hace necesaria su complementación.

1. INTRODUCCION A LA LÓGICA NORMATIVA

En la conversación cotidiana decimos que algo “*es lógico*” cuando es obvio u ocurre normalmente (como por ejemplo “es lógico que uno tenga sueño después de un día de trabajo”). Con ello nos estamos refiriendo a hechos que, según nuestra propia experiencia o la experiencia colectiva reflejada en las creencias y conocimientos que adquirimos por participar de una comunidad, entendemos que suceden en forma regular o de un modo que no nos causan sorpresa. Sin embargo no es a esta idea de “*lógica*” a que aludiremos en este apartado. Aquí vamos a restringirnos a un uso estricto, mas técnico, del término y por ello diremos que la lógica es una disciplina que estudia sólo *la forma* del razonamiento, independientemente de que el contenido de los juicios concuerde con la experiencia.

El problema central del que se ocupa la lógica es la distinción entre los razonamientos correctos y los incorrectos. Puede decirse también que su objeto es el estudio de los razonamientos deductivos. Un razonamiento correcto, o válido, es un conjunto de proposiciones en el que una de ellas, llamada conclusión, está fundada o se infiere de las otras, llamadas premisas¹.

Se denomina a la lógica ciencia “formal” porque, al igual que las matemáticas, estudia *las formas* de los razonamientos correctos, independientemente de *los contenidos* de estos razonamientos.

Por ejemplo:

De	<i>Todo B es C</i>
y de	<i>Todo A es B</i> (premisas)

se infiere que	<i>Todo A es C</i> (conclusión).

Este es un razonamiento correcto cualquiera sea el significado de los términos A, B y C. Tanto las premisas como la conclusión son *proposiciones*, o sea *expresiones lingüísticas que poseen una función informativa (afirman o niegan algo) y de las cuales tiene sentido decir que son verdaderas o falsas*. La lógica atiende a las relaciones entre proposiciones y de acuerdo a estas relaciones se entiende que un razonamiento correcto es aquel que garantiza la conservación de la verdad, esto es que **si las premisas son verdaderas la conclusión es necesariamente verdadera**.

Las proposiciones del ejemplo anterior (de la forma *A es B*) son *simples* o *atómicas*, pues no contienen dentro de sí otra proposición. Existen también proposiciones *compuestas* o *moleculares*, formadas por dos o más proposiciones simples (por ejemplo: *Hubo elecciones y se*

¹Esta brevísima introducción se restringe a la lógica deductiva y no pretende sino resumir conocimientos que el estudiante debe poseer. Nociones básicas sobre lógica son imprescindibles a lo largo de toda la materia, tanto para la presente unidad como para comprender el desarrollo de temas como las teorías del orden jurídico, los conceptos jurídicos básicos y la interpretación y argumentación jurídicas. Para quien considere que tiene dificultades con esas nociones resultará conveniente consultar alguno de los numerosos manuales que introducen al tema. Son recomendables Copi, Irving; *Introducción a la lógica* (4ª ed. 1972), Buenos Aires, Eudeba, 1990 (Cap. 1), o Gianella, Alicia; *Lógica simbólica y elementos de metodología de la ciencia* (1975), Buenos Aires, El Ateneo, 1988 (Caps. 1 a 3), o Klimovsky, Gregorio; *Las desventuras del conocimiento científico*, Buenos Aires, AZ Editora, 1995 (Cap. 5).

eligieron diputados). La lógica proposicional o simbólica estudia los razonamientos formados por varias proposiciones conectadas entre sí del mismo modo que en el lenguaje ordinario unimos oraciones mediante las expresiones “y”, “o”, “si... entonces”, etc.. Para formalizar estos razonamientos se simbolizan las proposiciones simples o atómicas con letras minúsculas (p , q , r , etc.) y las conexiones mediante signos que hacen referencia a un especial modo en que están vinculadas las proposiciones.

Por ejemplo, la función que cumple la expresión “y” en el lenguaje se denomina *conjunción* y suele simbolizarse mediante un punto. Una proposición como

Pedro vino (p) y ($\cdot$) Juan se fue (q)

se simboliza

$p \cdot q$

y como cualquier expresión similar sólo es verdadera si son verdaderas ambas proposiciones. Mediante esta formulación simbólica la lógica procura “encasillar” en un grupo limitado de signos los razonamientos que realizamos a diario utilizando el lenguaje ordinario y de esta manera establecer las reglas que permitan apreciar claramente su corrección o incorrección, del mismo modo que se utiliza el álgebra en matemáticas.

Esta formalización, como ya se dijo, se limita al *uso informativo* del lenguaje, de modo que sólo pretende estudiar los razonamientos correctos mediante los cuales de premisas verdaderas se infieren conclusiones verdaderas.

A partir de 1951 Georg Henrik von Wright ha desarrollado una lógica que llamó *deóntica*, procurando formalizar los razonamientos que incluyen enunciados normativos, o sea enunciados que no se refieren a cómo las cosas son (uso informativo del lenguaje) sino a cómo *deben* ser (uso directivo o prescriptivo). Su objetivo era formalizar los enunciados normativos y sus conexiones del mismo modo en que la lógica proposicional lo ha hecho con los enunciados informativos. Al profundizar su tarea encontró que la lógica proposicional resultaba inadecuada para expresar este tipo de razonamientos. Es decir, que si en la formulación de un razonamiento correcto de acuerdo a la lógica proposicional se sustituían las proposiciones (enunciados del tipo *A es B*) por *normas* (enunciados del tipo *A debe ser B*), la formulación dejaba de expresar un razonamiento correcto. En 1963 publicó *Norm and Action (Norma y Acción)* luego de considerar que era necesario inventar nuevas herramientas lógicas, ya que la lógica de la acción era un requisito necesario para la lógica deóntica y “*el simbolismo de la llamada lógica proposicional era inadecuado para simbolizar los varios modos de acción*”.

Von Wright no es abogado sino un filósofo dedicado a estudios sobre lógica, pero sus investigaciones cobran relevancia para la teoría del derecho por cuanto los razonamientos jurídicos son habitualmente normativos: parten de premisas entre las cuales hay al menos una norma y se infieren normas como conclusiones. Es por ello que sus estudios han sido recogidos por varios filósofos del derecho como punto de partida para elaborar un lenguaje formal que, depurado de lo que llaman “vicios” del lenguaje ordinario, permita distinguir con claridad los razonamientos normativos válidos de los que no lo son.

El libro *Norma y Acción*, incluido en la bibliografía de la cátedra, está enteramente dedicado a la formulación de una lógica de la acción, de allí que continuamente se haga referencia a la formalización y al significado de los símbolos introducidos. Nosotros no vamos a seguir a von Wright en esta tarea pues no está en el programa de la materia el desarrollo de los estudios de la lógica deóntica². Sin embargo tomaremos de la bibliografía principalmente el esclarecimiento de los principales significados de términos básicos del vocabulario jurídico como “ley”, “norma”, “prescripción”, “acción”, “acto”, “resultado”, “consecuencias”, etc.

La tipología de las normas de von Wright³.

Hasta ahora hemos dado por supuesto el conocimiento de lo que es una *norma* y en general se la ha identificado con el uso directivo o prescriptivo del lenguaje⁴. En este punto se caracterizarán las diferentes especies o tipos de normas a fin de precisar la idea.

Habitualmente se define al derecho como “conjunto de normas”. Definiciones de este tipo también se hallan al describirse las distintas ramas del derecho, así por ejemplo se dice que “el derecho penal es el conjunto de normas que regulan el poder punitivo del estado” o que “el derecho laboral es el conjunto de normas que regulan la relación entre trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores”. En todos los casos se da por supuesto un tipo especial de normas que son las normas *jurídicas*. ¿Pero qué es una *norma*?

En general (aunque no siempre) cuando aludimos a *norma* o *normalidad* hacemos referencias a directivas, es decir a expresiones formuladas con la intención de influir en el comportamiento de otro. Aunque no de todas las directivas se dice que son *normas*; especialmente no son normas las directivas u órdenes fundadas exclusivamente en el uso de la fuerza. Tampoco toda norma es una directiva.

Como sinónimos parciales de *norma* se suelen utilizar los términos “ley”, “ordenanza”, “modelo”, “regla”, etc., aludiendo a comportamientos *generales* similares o uniformes (aunque por extensión también se llega a hablar de *normas individuales*).

Von Wright en lugar de dar una definición de *norma* hace una “tipología” de los diversos usos de esta palabra. Una *tipología* es en cierto modo similar a una clasificación pero en un sentido más débil ya que clasificar sugiere agrupar en conjuntos delimitados y en cambio establecer un *tipo* es señalar un ejemplo familiar (que llamaremos “prototipo” o “paradigma”) y agrupar los casos en razón de su parecido con este ejemplo.

² Para quien tenga interés en profundizar el tema, además de la obra de von Wright puede abordar Kalinowsky, Georges; *Introducción a la lógica jurídica* (1965), Buenos Aires, Eudeba, 1973, y bibliografía citada en voz “deóntico por Ferrater Mora, José; *Diccionario de Filosofía* (6ª ed. 1976), Madrid, Alianza, 1980.

³ Este punto se encuentra desarrollado en el capítulo 1 de *Norma y acción* de von Wright y resumido en el capítulo II de Nino, Carlos; *Introducción al análisis del derecho* (2ª ed. 1980), Buenos Aires, Astrea, 1996. Lo que sigue no pretende sustituir esas lecturas sino complementarlas.

⁴ Respecto al uso del lenguaje nos remitimos al punto 6 de la unidad I y especialmente a Nino, Carlos; op cit. cap. V.

Comienza por señalar distintos usos de la palabra “ley”, habitualmente asociada a *norma*:

- *Las leyes de la naturaleza*, que son hipótesis acerca de regularidades existentes en los fenómenos naturales y son típicamente *descriptivas*, esto es, pueden ser verdaderas o falsas. Un ejemplo: *Los planetas describen órbitas con forma de elipse en uno de cuyos focos se encuentra el sol* (llamada “primera ley de Képler”). Si se observa que un planeta no describe una órbita de ese tipo entonces la ley sería falsa, no es del caso pretender “obligar” al planeta a “cumplir” con la ley.
- *Las leyes del estado*, constituyen directivas que ordenan la conducta humana y son típicamente *prescriptivas*. No puede decirse que estas leyes sean verdaderas o falsas. Si una persona fuma en un lugar en donde está prohibido fumar, eso no significa que la prohibición sea “falsa”, sino que esa persona está infringiendo la ley y puede ser obligada a apagar el cigarrillo o a soportar alguna otra sanción.
- *Las leyes de la lógica (y de las matemáticas)*. No pueden ubicarse en ninguno de los dos tipos anteriores. Puede decirse que son *prescriptivas* en tanto establecen las reglas de los razonamientos correctos pero en un sentido distinto en que se llama prescriptivas a las leyes del estado. También puede decirse que *describen* los razonamientos correctos, pero no de un modo que podría ser refutado por la observación empírica, de manera que sería una descripción diferente de la que tipifican las leyes de la naturaleza. Von Wright dice que se acomodan mejor con el tipo de normas que rigen los juegos (habitualmente se toma como ejemplo paradigmático al ajedrez) y las llama *determinativas*.

De los tres tipos de leyes el primero está constituido claramente por *proposiciones* (enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos) y es ajeno al uso del término *norma* como sinónimo. Las otras dos clases sí pueden ser formuladas como *normas*, aunque no agotan una clasificación. Von Wright distingue tres tipos de normas principales:

1. Las *reglas de juego*, a las que asigna el nombre de *reglas* y atribuye, como se vio, carácter *determinativo*. Es un tipo de normas cuyo seguimiento *determina* que se está realizando cierta actividad regulada precisamente por dichas normas. El ajedrez, por ejemplo, consiste en un conjunto de estas reglas que establecen cómo debe ser el tablero, qué tipo de piezas se usarán, de qué modo es permitido mover a éstas, etc. Se dice que estas reglas son *determinativas* o *constitutivas* de la actividad porque si uno quiere jugar al ajedrez debe aplicarlas de acuerdo a lo prescripto en el reglamento. Su falta de seguimiento no produce ninguna sanción sino que implica que uno no está jugando ese juego. H.L. Hart⁵ hace hincapié en que el derecho no sólo está constituido por normas seguidas de sanción (prescriptivas) sino también por reglas de este tipo: quien “promulga” una ley sin estar autorizado para ello no promulga ninguna ley, quien redacta un testamento sin las formalidades que el código civil establece no recibe ninguna sanción sino que el documento así redactado carecerá de los efectos jurídicos propios de los testamentos.
2. Las *prescripciones o regulaciones*, cuyo prototipo son las leyes del estado. Dimanan de una autoridad normativa y se dirigen a uno o varios sujetos con el fin de que adopten cierta

conducta. “Para dar efectividad a su voluntad”, dice von Wright, “la autoridad añade una sanción, o amenaza, o castigo a la norma”. Esta aclaración es particularmente importante ya que veremos que para Hans Kelsen es la amenaza de sanción lo que caracteriza a la prescripción, de modo que una norma que carece de la posibilidad de aplicar una sanción por su incumplimiento no es una norma jurídica. Cabe aclarar, por último, que aunque el modelo o paradigma de las prescripciones son las leyes del estado (y al decir “leyes” incluimos las ordenanzas, decretos, resoluciones, etc., de los diferentes órganos estatales), también deben ser incluidos en este tipo los estatutos de una sociedad, las estipulaciones contractuales, los reglamentos internos de un club, etc., puesto que todos ellos se utilizan, dentro de su ámbito de aplicación, de un modo similar al de las leyes del estado.

3. Las *normas técnicas, o directrices, o instrucciones*, indican los medios necesarios para arribar a un fin. Aunque, como sucede con toda norma, no son susceptibles de verdad o falsedad, presuponen una proposición (que von Wright denomina *anankástica*) que sí puede ser verdadera o falsa⁶. Esta es la proposición que dice que el medio indicado por la norma es condición necesaria para alcanzar el fin deseado.

En adición a estos tres tipos von Wright habla de “tres grupos menores de particular importancia”:

1. Las *costumbres*. Son “*prescripciones anónimas*” por cuanto, al igual que las prescripciones, ordenan determinados modos de conducta cuyo incumplimiento es sancionado mediante actitudes de rechazo por parte de la comunidad. Pero también tienen el carácter de reglas, en tanto no sólo su seguimiento determina al sujeto como perteneciente a una cierta comunidad, sino que además *define* a esta comunidad como caracterizada por poseer dichas costumbres. Son estas costumbres en el modo de relacionarse, de establecer vínculos familiares, de celebrar festividades, de organizarse para trabajar o para divertirse, etc., las que constituyen normas características de una comunidad de cultura que permiten diferenciar a un pueblo de otro y que identifican a cada individuo con su grupo o nacionalidad. Es el seguimiento de estas normas lo que nos lleva a caracterizar a una comunidad como “esquimales” y a un individuo como perteneciente a esa comunidad, y a distinguir ambos –comunidad e individuo- de otros grupos como, para dar un ejemplo, los brasileños.
2. Los *principios morales*. Von Wright llama así a las normas que establecen deberes u obligaciones morales, algunas de las cuales participan a la vez de características determinativas y prescriptivas (al igual que las costumbres) y otras se asemejan a las instrucciones, ya que señalan los medios para una finalidad moral⁷.
3. Las *reglas ideales*. Este es un tipo especial de directiva y difícilmente pueda llamarse “norma” en el mismo sentido en que se ha denominado así a todos los ejemplos vistos hasta ahora. No parecen claros los motivos de su inclusión en una obra dedicada a la lógica deóntica puesto que, a diferencia de los tipos anteriores, no pueden formularse en correlato con un lenguaje de la acción. Todos los tipos vistos hasta ahora (reglas, prescripciones, instrucciones, costumbres y principios morales) establecen directivas para acciones

⁵ En *El concepto de derecho* (1961), Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995.

⁶ En Nino, op. cit., pág. 68, pueden verse las críticas a esta distinción entre “norma técnica” y “proposición anankástica”.

⁷ Me remito a von Wright, op. cit., págs. 30/32 y al resumen de Nino, op. cit., pág. 70.

determinadas. No toman en cuenta la historia personal del sujeto al que se dirigen ni las condiciones personales que no influyan en la acción señalada en el caso. Por ejemplo, si una norma dice “no robar”, o mejor, “el que roba será castigado”, el contenido de la norma es la acción prohibida (robar), sin que sea relevante para establecer si la norma se ha cumplido saber si el destinatario de la acción es una buena o mala persona o si ha robado antes o no. En cambio estas *reglas ideales* no hacen referencia a una acción sino a la posesión de una virtud. Ellas prescriben ser una persona *justa*, un soldado *valiente*, un juez *prudente*, etc. sin disponer acciones determinadas sino todas aquellas que en un contexto dado permitan aproximarse al ideal de una cierta clase de persona. Aunque podría suponerse que se trata de una formulación de buenas intenciones sin mayores efectos prácticos, lo cierto es que es común encontrar expresiones de este tipo en las leyes⁸, que funcionan como marco interpretativo en el que encuentran sentido las normas referidas a acciones determinadas⁹. Con acierto von Wright pone en duda que este tipo de reglas pueda reducirse a un conjunto de normas referidas a acciones, es decir, que –por ejemplo- el requerimiento de ser un hombre o mujer *justo* pueda formularse haciendo alusión a cada una de las acciones que él o ella debería realizar¹⁰. No es este el lugar para desarrollar el punto, pero es necesario destacar la importancia de este tipo de reglas a fin de poner en cuestión la inclinación *moderna*¹¹ que, tanto en el derecho como en la ética, presta una atención casi excluyente a las *normas de acción* y descuida este tipo de *reglas ideales* contruidos por una comunidad alrededor de ejemplos dignos de imitarse.

Normas y proposiciones normativas: lenguaje y verdad

Este punto atañe a la relación entre normas y verdad¹², a la cuestión de si podemos preguntarnos si las normas son verdaderas o falsas y a qué querríamos decir con ello. Debemos recordar una distinción conceptual¹³ que se hizo acerca de dos tipos de uso del lenguaje: el uso *descriptivo o informativo* y el uso *prescriptivo o directivo* (Unidad I, punto 1.6). En el primero tiene sentido decir si algo es verdadero o falso, pero ello no ocurre con el segundo. Esta distinción guarda relación con el contraste estudiado entre las leyes de la naturaleza (descriptivas) y las leyes del estado (prescriptivas).

⁸ Por ejemplo: “Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.” (art. 63 de la ley de contrato de trabajo).

⁹ De este modo, continuando con el ejemplo anterior, la acción que pueda constituir “injuria grave” que justifica el despido (art. 242 de la ley de contrato de trabajo) no puede determinarse independientemente de si en el caso se trata de un buen o mal trabajador o un buen o mal empleador. La mayoría de las normas del derecho de familia no pueden aplicarse si se dejan de lado este tipo de *reglas ideales*.

¹⁰ Kelsen, por el contrario dice que “un hombre es justo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo” (¿Qué es justicia? [1971], Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, pág. 36), pero para ello hay que sostener, como hace Kelsen, que el orden normativo es completo y que toda acción está prevista en una norma preexistente, lo que es –por lo menos- discutible.

¹¹ No uso el término con el significado de “actual” o “de última onda”, sino que me refiero al pensamiento característico de *la modernidad*, originado con posterioridad al renacimiento.

¹² Se encuentra desarrollado en von Wright, op. cit. págs.118/121 y Nino, op. cit., págs.87/88.

¹³ Al decir que ésta es una “distinción conceptual” quiero resaltar que ello no implica que en la práctica real y cotidiana del lenguaje podamos distinguir siempre el uso descriptivo del prescriptivo. Habitualmente ocurrirá lo contrario, es decir que ambos estén confundidos, ya que la realidad humana no es sólo un mundo de hechos físicos sino también un mundo de normas y valores, y el lenguaje que interactúa con esta realidad (la refleja y a la vez la crea) no puede componerse de modo diferente. Sin

Como nuestro interés es la teoría del derecho, con el fin de simplificar la exposición vamos a enfocar la atención exclusivamente en las prescripciones, dejando de lado los otros tipos de normas. De aquí en más debe entenderse que toda referencia a normas alude básicamente a normas prescriptivas¹⁴.

Tomemos un ejemplo para presentar el problema. Supongamos que un policía de tránsito dice “*Usted puede estacionar su coche en aquel lugar*”. ¿Está informando acerca de una norma que permite estacionar o está dando él un permiso para estacionar?

En el primer caso (información) el policía puede estar en lo cierto pero también podría equivocarse (tal vez haya una ordenanza prohibiendo estacionar allí), de modo que el enunciado “*puede estacionar...*” es susceptible de ser verdadero o falso. En el segundo caso el policía está dando un permiso (damos por supuesto que tendría facultades para ello) y el enunciado consiste en la formulación de una norma, por lo que no podríamos calificarlo de verdadero ni de falso.

Establecer si un enunciado es descriptivo o prescriptivo no depende entonces del aspecto (en el ejemplo vimos que se trata del mismo enunciado) sino de las circunstancias en que aquel es formulado. Es el contexto el que nos dice si una oración es un enunciado descriptivo o una norma.

Un enunciado descriptivo de este tipo es un enunciado que habla acerca de la existencia o inexistencia de una norma. Kelsen le llama *enunciado normativo* (o proposición normativa)¹⁵ y dice que la ciencia del derecho está compuesta por proposiciones normativas y tiene por objeto a las normas jurídicas. “*En la diferenciación entre enunciado jurídico y norma jurídica se expresa la distinción entre la función del conocimiento jurídico, y la función, enteramente distinta, que cumple la autoridad jurídica representada por órganos de la comunidad jurídica. La ciencia del derecho tiene que conocer el derecho –por decir así, desde fuera-, y fundándose en ese conocimiento, describirlo. Los órganos jurídicos tienen, como autoridad jurídica, ante todo que producir el derecho, para que pueda luego ser conocido y descripto por la ciencia jurídica.*”¹⁶

Así, con base en la distinción lógica entre enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos podemos distinguir entre proposiciones normativas y normas. Esta diferenciación conceptual no siempre es nítida. Aparece clara si tomamos a un enunciado como “*en Holanda están permitidos la tenencia y el consumo de drogas ‘blandas’*”, puesto que no caben dudas que, dicho en Argentina, no se está dando un permiso al interlocutor sino haciendo una observación acerca de la ley holandesa. Sin embargo, cuando un texto jurídico describe al derecho “desde adentro” junto con descripciones (mas bien transcripciones) de lo que las normas “dicen” se

embargo la distinción permite tener una idea de cómo a veces ponemos el acento en una o en otra forma de usar el lenguaje.

¹⁴ Debe quedar en claro que esta restricción consiste en una elección motivada por fines pedagógicos. Sería engañoso aceptar sin discusión que al derecho sólo le interesan las prescripciones.

¹⁵ Kelsen, Hans; *Teoría pura del derecho* (1960), México, Ed. Porrúa, 1993, Cap. III. Aunque en teoría del lenguaje *enunciado* y *proposición* no son lo mismo (la segunda alude al significado y el primero a la forma, de allí que diferentes enunciados podrían decir la misma proposición), Nino llama *proposiciones* a lo que Kelsen (y también von Wright) se refieren como *enunciados*, y el programa sigue la denominación dada por Nino.

¹⁶ *Ibid.*, pág. 85.

encuentran numerosas prescripciones concernientes a cómo deben interpretarse. Aunque la distinción a que apunta Kelsen es útil para establecer diferenciaciones en el plano teórico y evitar que la opinión de un autor sea presentada como una descripción “incontaminada” de la norma, la pretensión de que el derecho como disciplina se limite a las proposiciones normativas parece exagerada ya que tomada al pie de la letra restringiría la tarea jurídica al mero registro de las normas en vigor. De hecho todos los juristas (incluido el propio Kelsen) formulan normas que presentan como una descripción del derecho vigente¹⁷. No sólo esa es la forma habitual de argumentación jurídica sino que en ello reside la fecundidad de los estudios de esta disciplina. De allí que la *doctrina* sea reconocida desde la antigüedad como una de las *fuentes* productoras del derecho¹⁸. Por eso la distinción entre *norma* y *proposición normativa*, aunque útil muchas veces como guía conceptual, es engañosa si se expone como una descripción adecuada de la práctica jurídica o como un criterio necesario para “depurar de imperfecciones políticas y morales” al derecho¹⁹.

2. INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA ACCION HUMANA ²⁰

Hemos visto que las normas prescriptivas se dirigen a motivar comportamientos humanos. A los fines introductorios, provisoriamente llamaremos *acciones* a todos estos comportamientos y diremos que esta noción “*está relacionada con la noción de suceso, es decir de un cambio en el mundo*”²¹. Con ello pretendemos destacar que una característica de la acción es producir un resultado en el mundo que podemos atribuir no al curso de la naturaleza sino a la intervención humana. Básicamente las normas prescriptivas (y en general todos los tipos normativos expuestos por von Wright, con excepción de las *reglas ideales*) se dirigen a influir en estas intervenciones prohibiendo, obligando o permitiendo acciones humanas.

Según Kelsen toda norma jurídica puede formularse de este modo: *Dado A debe ser S* (en donde A es la hipótesis de una acción y S es la sanción que debe adoptar un órgano estatal cuando esta acción se realiza). En esta fórmula pueden expresarse tanto las normas prohibitivas como las obligatorias y las permisivas. Es fácil observar cómo esta tesis coincide con la norma prohibitiva: Cuando se dé A (la acción prohibida) debe aplicarse una sanción. También es sencillo ver cómo las normas obligatorias se ajustan a la fórmula: En este supuesto A es la acción negativa consistente en el no cumplimiento de la obligación, de modo que quien no cumple debe ser sancionado. Mostrar cómo una norma permisiva también cuadra en la formulación de Kelsen es algo más complejo: En este caso A consistiría en la acción de impedir actuar a quien tiene un permiso, de modo que la norma en realidad no se dirige a quien parece

¹⁷ Un ejemplo tomado al azar: “...**no puede haber la menor duda** acerca de que nuestra Constitución tornó imperativo para nuestro país un procedimiento penal cuyo eje principal era la culminación en un juicio oral, público, contradictorio y continuo...” (Maier, Julio; *Derecho procesal penal argentino*, Buenos Aires, Hammurabi, 1989, T.1b, pág. 424, el resaltado me pertenece). Sin embargo, pese al énfasis de la expresión “no puede haber la menor duda”, la mayor parte de los juristas considera que el juicio escrito y discontinuo (opuesto al oral y continuo), no es inconstitucional. Lo que no obsta a que –como es mi opinión– se considere que el juicio penal oral y contradictorio sea un importante paso hacia el objetivo de democratizar las prácticas cotidianas, en este caso en el ámbito de las decisiones judiciales.

¹⁸ La discusión acerca de la doctrina como fuente del derecho se estudiará en la unidad V.

¹⁹ En esto reside, en mi opinión, lo inadecuado del enfoque de Kelsen (y otros similares) que pretenden separar de modo tajante la *ciencia* del derecho de la teoría moral y política.

²⁰ Este punto está completamente reformulado en relación a la bibliografía de cátedra.

²¹ Von Wright, op. cit., pág. 53. Von Wright utiliza el término “*acto*” para la idea que aquí, siguiendo una terminología más extendida, llamaré “*acción*”.

ser su destinatario sino a todos aquellos que podrían limitar su conducta. O sea, que alguien goza de un permiso significa que aquel que le obstaculice su ejercicio debe ser sancionado. Como se ve, todos los tipos de normas jurídicas pueden reducirse a este esquema lógico: Dado A (acción) debe ser S (sanción), lo que supone que para que la norma se aplique tiene que haber:

1º) una descripción del mundo (“A existe”), y

2º) un mandato al órgano estatal (“debe aplicar la sanción”)²².

Lo que nos va a ocupar aquí es qué es esa “descripción del mundo” consistente en decir que ha tenido lugar una acción. La cuestión parece sencilla y no justificaría mayor desarrollo si nos limitáramos a pensar en los casos claros de la vida cotidiana. El código penal dice que “Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años al que matare a otro...” (art. 79), de modo que si está probado que intencionalmente alguien clavó un cuchillo en el pecho a otro (quien murió por ello), no hay dudas de que “lo mató” (como dice el código) y en consecuencia el juez debe dictar una condena. Con ejemplos como este no parece que fuera necesaria demasiada indagación teórica.

Una noción de acción, que podríamos llamar *empirista*, descansa en la consideración de ejemplos similares. Según ella no hay una diferencia relevante entre describir comportamientos humanos y describir sucesos de la naturaleza. Del mismo modo que observamos cómo *el fuego quema un árbol* podemos ver cómo *un hombre mata a otro*. Para esta postura (que suele utilizar el término *conducta* en lugar del de *acción*, ya que este último tiene connotaciones psicológicas) se trata de descripciones de comportamientos corporales verificables por cualquier observador, cuyas alteraciones en el mundo se rigen por las leyes de la naturaleza. Así, quien clava un cuchillo a otro interviene de tal modo en el funcionamiento natural de sus órganos anatómicos que produce su muerte.

Sin embargo la vida social es más compleja. Las acciones no se realizan nunca de un modo bien diferenciado y recortadas unas de otras, como aparecen las fronteras en los mapas, sino que se llevan a cabo de manera continua, entremezcladas entre sí, y sólo mediante cierto proceso de abstracción podemos distinguirlas dejando de lado los aspectos que no nos interesan para la descripción. La acción de ejecutar un homicidio algo complejo (como por ejemplo, mediante una carta explosiva o con envenenamiento) puede estar entrecortada por distracciones, conversaciones, interrupciones para realizar otra actividad, etc., y sin embargo no dejamos de identificarla como una sola acción. En muchos casos, además, hace falta la colaboración, conciente o inconciente, de otras personas, y ello ya desfigura por completo la idea simple y no problemática que exhibimos al principio. ¿Podemos decir que el mensajero que entregó un paquete con una bomba *mató* a quien después resultó víctima de la explosión? ¿El mozo de restaurant que llevó al cliente un plato de comida que otro había envenenado *mató* al que murió por ello? ¿Las respuestas serían las mismas en caso de que el mensajero o el mozo conocieran el contenido letal de lo que entregaban? ¿Y si este contenido también era conocido por las víctimas

²² La noción de norma según Kelsen se presta a muchas críticas que no es del caso formular aquí porque mi interés es destacar cómo la idea de *acción* está lógicamente vinculada a la de *norma*, y de este modo mostrar porqué se justifica que el programa de la materia incluya a la teoría de la acción dentro de la unidad destinada a la teoría de las normas.

no obstante lo cual éstas optaron por morir? En algunos de estos casos diríamos que *mató* y en otros no, y sin embargo no habría nada en una “descripción” centrada en el comportamiento externo que distinguiera a un supuesto de otro. La película que mostrara cómo el mozo llevó un plato al cliente y cómo éste lo probó y cayó muerto, no nos aclararía nada cuando quisiéramos averiguar si el mozo *lo mató* o *no lo mató*.

Otro tipo de problemas se produce con las *abstenciones*. En el derecho penal se castigan delitos llamados *de omisión*²³ que consisten en un “no hacer”. ¿Cómo podría observarse este tipo de acciones? Visto desde aquella perspectiva la respuesta parece imposible. Sin embargo, no nos resulta difícil establecer que los padres *mataron* a su bebé cuando lo dejaron morir de hambre (*omitiendo* alimentarlo).

Estos pocos ejemplos simples nos muestran tanto la complicación como la importancia del tema (esta última tiene lugar cuando, por ejemplo, de la determinación de la existencia de la acción puede depender la libertad de una persona). **El problema central de la teoría de la acción humana es dilucidar con qué criterios podemos atribuir a alguien la ocurrencia de un suceso de modo de decir que esa persona hizo tal cosa.**

El problema de cómo describimos las acciones humanas ha provocado investigaciones paralelas en el derecho (sobre todo en el derecho penal) y en epistemología de las ciencias sociales, por lo que parece conveniente exponer sintéticamente las grandes líneas de los posicionamientos teóricos así como las similitudes que se encuentran en ambas disciplinas.

En epistemología, la postura empirista tradicional considera que el método científico es el mismo en las ciencias naturales y en las ciencias sociales y, tomando como ideal o canon a la física matemática, desarrolla una explicación *causal* de la conducta humana, subsumiéndola en leyes generales de comportamiento²⁴ sin que se justifique acudir a *intenciones* o *motivaciones* ocultas e inaccesibles a la observación. Un representante de esta posición dirá que el conocimiento “...supone como condición necesaria de su adecuado fundamento la posibilidad de verificar esas formulaciones a través de observaciones sensoriales controladas por cualquiera que quiera tomarse el trabajo de verificarlas”²⁵. La alusión se hace aquí a una *conducta manifiesta* (entendida en términos de movimientos corporales) que no presupone ni necesita para ser explicada la referencia al *sentido* o *intencionalidad* de las personas.

Otra tradición, que llamaremos *comprensivista*²⁶, consideró que las ciencias sociales debían diferir en su metodología de las ciencias naturales por cuanto es imposible hacer inteligible la conducta de los seres humanos sin atender a la finalidad, al sentido que éstos

²³ Centraremos los ejemplos en el derecho penal porque en otras ramas del derecho el antecedente de sanción suele estar constituido por un complejo compuesto por la acción, múltiples cadenas causales de imputación y un resultado, lo que oscurece la exposición de los problemas de la teoría de la acción. Basta pensar en la responsabilidad llamada “objetiva” (sin culpa), o la responsabilidad por la acción ajena o la de las personas jurídicas, para ver cómo el problema de describir una acción se confunde con otros que no es necesario tratar aquí.

²⁴ Tomo esta síntesis de von Wright, Georg Henrik; *Explicación y comprensión* (1971), Madrid, Alianza, 1987, pág. 21.

²⁵ Nagel, Ernest; *La estructura de la ciencia* (1961), Barcelona, Paidós, 1981, pág.436.

imprimen a sus acciones. El problema metodológico de esta postura consistía en que las finalidades eran “contenidos mentales” de los sujetos inaccesibles a un observador externo, lo que imposibilitaba la verificación objetiva²⁷.

En el derecho penal es imposible eludir la cuestión de la finalidad de las acciones, ya que los delitos cometidos intencionalmente (*dolosos*) son más graves y están descriptos en la ley de modo distinto que los cometidos por mera imprudencia (*culposos*). Sin embargo una tradición llamada *causalista* consideró que para establecer si una conducta humana consistía en un delito de acuerdo a la redacción de la ley, primero había que describir la acción sólo en términos de comportamientos corporales y resultados y examinar al final (luego de ver si se daban causales de justificación, como legítima defensa y otras) si había existido intencionalidad o negligencia. Las dificultades que esta posición acarrea ya se vieron más arriba con unos pocos ejemplos: además de no poder dar cuenta de los casos en que describimos una omisión, aún en las conductas positivas el mero comportamiento físico puede no decirnos nada respecto a si la acción se realizó o no.

Otra postura, iniciada con la corriente *finalista*, entendió que no podía describirse la acción humana si no era atendiendo desde un primer momento a la intencionalidad del sujeto, ya que es ésta la que nos permite calificar a la acción como tal. Las consecuencias prácticas de esta posición consisten en que admite casos en los que el sujeto no es culpable aunque haya realizado la acción, supuestos que se dan en situaciones extremas como las motivadas en diferencias culturales, etc., ya que en tales ocasiones no podría ser exigible otra conducta²⁸.

No es este el lugar para desarrollar el tema con la extensión que merece. Al respecto me voy a limitar a indicar los caminos teóricos que se han seguido para superar lo que aparecían como diferencias irresolubles.

El primer paso se dio con el giro que la filosofía experimentó en la consideración del *lenguaje ordinario*. En lugar de suponer que el lenguaje consistía en un *espejo* del mundo, en el que el acierto de una descripción se daba en la medida en que mejor reflejara o representara al hecho descrito, se observó que el lenguaje constituía una multiplicidad de reglas y usos propios de una *forma de vida* de una comunidad, que contaba con la propiedad “... *no solamente de articular la experiencia, sino de conservar, gracias a una especie de selección natural, las expresiones más adecuadas, las distinciones sutiles más apropiadas a las circunstancias del actuar humano*”²⁹. Así, usar un término como *acción* en diferentes casos, no implica agrupar los hechos a los que es aplicado mediante un denominador común que constituiría su “esencia”, sino

²⁶ La dicotomía *explicación* vs. *comprensión*, como característica de estas dos tradiciones, fue introducida en Alemania a fines del siglo XIX. Von Wright (1971), pág. 23.

²⁷ En esta síntesis dejo de lado la metodología de los “tipos ideales” de Max Weber porque llevaría a desarrollos alejados de los propósitos del trabajo y porque en definitiva aquella también es merecedora de las críticas lanzadas a la falta de verificabilidad de las propuestas comprensivistas.

²⁸ La explicación más clara y detallada de ambas posiciones requiere una extensión que excede de lejos los límites de este trabajo y es más propia del estudio del derecho penal. Parece que Nino no entiende la importancia de las diferencias cuando sugiere que se trata de una disputa puramente “semántica” (op. cit., pág. 253). Sin embargo un penalista de la vieja escuela, como Ricardo Núñez, advierte claramente que las teorías posteriores introducen motivos de no aplicación de la ley penal que él entiende violentan el código (ver *Derecho penal argentino* [1959], Buenos Aires, Lerner, 1964, T. I, pág. 231).

²⁹ Ricoeur, Paul; *El discurso de la acción* (1977), Madrid, Cátedra, 1988, pág. 12.

en relacionarlos entre sí mediante analogías y similitudes que pueden caracterizarse con la expresión *parecidos de familia*. Este fenómeno, que también se denominó “textura abierta” del lenguaje no es una “enfermedad” del habla natural que la ciencia debiera pretender eliminar mediante la construcción de un idioma perfecto, sino una necesidad de la operatividad del lenguaje, que requiere cierta indeterminación para su uso en una potencialmente infinita diversidad de circunstancias³⁰.

De allí que en la descripción de la acción humana no podamos emplear las reglas con que agrupamos y clasificamos a los fenómenos físicos, sino que nos aproximamos a ella mediante los ejemplos de nuestra vida cotidiana, aprendidos en la interacción humana en donde adquirimos, a través del uso del lenguaje, la destreza para aplicar los términos conocidos a situaciones inesperadas. Se ha utilizado la idea de “*juegos de lenguaje*” para señalar que, tal como ocurre con las reglas de juego, el significado de un término no se encuentra aislado sino que necesariamente está referido a los otros significados del mismo “juego”, que integran una *red conceptual*. De igual modo que en el ajedrez no podríamos comprender el sentido de una jugada si no conocemos las reglas en su conjunto, cómo mueven las otras piezas, qué movidas alternativas eran posibles, qué finalidad tiene el juego, etc., todo lo cual requiere un conocimiento global previo, así también hemos aprendido *socialmente* a identificar a la “acción”, a ubicarla en la misma red en que se encuentran los conceptos de intención, de fin, de razón para actuar, de motivo, de deseo, de preferencia, de elección, de agente, de responsabilidad, etc., de modo que el cambio en cualquiera de estos conceptos, como sucede cuando varían nuestras costumbres, modifica a todos los otros en mayor o menor medida.

¿Qué nos aclara esto con respecto a nuestro problema concreto? En primer lugar que para responder a la pregunta acerca de si “*esta persona hizo tal cosa*” (como, en el ejemplo ya visto, si el mozo *mató* al comensal) debemos atender al contexto en que se formula la pregunta, esto es al *uso* que se requiere del lenguaje de la norma. Diríamos que *no lo mató* si no sabía ni podía saber que la comida estaba envenenada y se pretende averiguar si debería ir a la cárcel. Podría, en cambio, establecerse que *sí lo hizo* si el fin es determinar su responsabilidad civil o el cierre del comercio por la municipalidad (lo que dependería, además, de otras circunstancias a las que no nos hemos referido). También él mismo podría sentir que *lo mató*, como una carga de conciencia más allá de que haya sido encontrado inocente por el derecho.

En segundo término, como las situaciones nuevas deben ser catalogadas en términos de las experiencias de una comunidad codificadas en el lenguaje, variaciones en estas experiencias por grupos distintos devienen en variaciones acerca del significado en los casos problemáticos, que no pueden resolverse mediante la apelación a un lenguaje o razonamiento “neutral”. “*La lógica de lo humano o de lo razonable es una razón impregnada de puntos de vista estimativos, de criterios de valoración, de pautas axiológicas, que, además, lleva a sus espaldas como aleccionamiento las enseñanzas recibidas de la experiencia propia y de la experiencia del prójimo a través de la historia*”³¹. De allí que frente al razonamiento deductivo puramente

³⁰ Para un mayor desarrollo de esta filosofía ver Wittgenstein, Ludwig; *Investigaciones filosóficas* (1953), Barcelona, Crítica, 1988.

³¹ L. Recaséns Siches, *Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX*, México, 1963, pág. 541; citado por Rodríguez Mourullo, Gonzalo; *Aplicación judicial del derecho y lógica de la argumentación jurídica*,

formal, el razonamiento jurídico es casi siempre controvertido y sólo muy raramente puede ser considerado como *correcto* o *incorrecto* de una manera impersonal³².

Por último, en cuestiones como las penales, en que determinar que la descripción de la acción realizada coincide con la que establece la norma lleva a las decisiones más gravosas para el individuo, vemos cómo la acción es distinguida como un todo en donde la intencionalidad juega un papel gravitante. Así von Wright distingue entre *resultado* y *consecuencia* de una acción. El primero es el estado de cosas terminal de un cambio, que *define* a la clase de acción de que se trata, y la consecuencia una segunda transformación ocurrida por efecto natural de ese estado terminal. No debe creerse, sin embargo, que podamos distinguir ambos mediante la observación empírica, ya que después dice que “...uno y el mismo cambio o estado de cosas puede ser a la vez resultado y consecuencia de una acción. Lo que hace lo uno o lo otro depende de la intención del agente al actuar y de otras circunstancias...”³³. Es la intención, no el mero comportamiento externo, lo que hace la diferencia entre describir la conducta del mozo como “mató al comensal” o como “llevó un plato de comida”.

Acto, habilidad y capacidad

La noción de *habilidad* adquiere importancia cuando debemos establecer si ha tenido lugar una abstención. Ya hemos visto que ateniéndonos exclusivamente al comportamiento corporal, aquella consiste en un “no hacer”, inobservable por definición. También vimos cómo puede haber ejemplos claros (en el sentido de “poco controvertidos”) en donde podemos identificar a una persona como autora de una abstención y responsabilizarla por ello (el caso de los padres que matan al hijo omitiendo alimentarlo). En general ligamos la idea de abstención con la de deber o conducta regular o esperada, de modo de resaltar *lo que no se hizo* y se esperaba que se hiciera. Esto sugiere que la descripción de una omisión requiere algunas precisiones adicionales.

Como aclaración previa diremos que –ateniéndonos a su uso jurídico predominante– llamaremos *acciones* tanto a los comportamientos positivos consistentes en un “hacer algo” como a los comportamientos negativos, abstenciones u omisiones.

¿Con qué pautas o ejemplos establecemos que una persona ha realizado una “abstención”?

En primer lugar alguien se abstiene de hacer algo cuando *puede* hacerlo. Nadie está en condiciones de “abstenerse” de realizar algo imposible, de modo que tienen que darse ciertas circunstancias de tiempo y lugar que hagan verosímil que la acción podría haber sucedido. Difícilmente una persona diría correctamente, aquí en el Comahue, algo así como “hoy me

Madrid, Civitas, 1988, pág. 27. Las formas en que diferentes experiencias de distintos grupos humanos se exhiben en una diversidad de significados pueden verse hoy en los fallos judiciales contradictorios acerca de si el sexo oral forzado constituye “violación”.

³² Rodríguez Mourullo, op. cit., pág. 34.

³³ Von Wright (1963), pág. 58.

abstuve de golpear al presidente de Rusia” fundándose en el hecho de que efectivamente no lo golpeó.

Pero además de darse esas circunstancias que permitirían actuar, von Wright muestra que para decir que alguien se abstuvo de hacer algo es necesario que *sepa cómo* hacerlo. Este requisito, sin embargo, lo podemos desdoblar en un requerimiento individual y en uno general.

La mayor parte de las veces ello implica tener una destreza especial o dominar la técnica necesaria para hacer algo. O sea que “... ese ‘saber cómo’ no consiste en la mera ‘comprensión’ intelectual del acto sino en la aptitud física o físico-mental de realizarlo efectiva y actualmente (no potencialmente), sea cual fuere su naturaleza. Este es el concepto de habilidad.”³⁴. Así por ejemplo cuando se dice que “Juan se abstuvo de escribir una carta” es porque se presupone que Juan sabe escribir.

Otras veces no es necesario que el sujeto posea la *habilidad* para imputarle que se ha abstenido de algo, pues basta con que tenga la *capacidad* para hacerlo. “El concepto de ‘capacidad’... es el de la ‘presunción’ basada en el estudio de la especie, de que bajo ciertas condiciones, un individuo o grupo de individuos de la misma, puede realizar un cierto tipo de acto o actos”³⁵.

Estas distinciones tienen importancia en el concepto de *omisión*. Aunque a veces “abstención” y “omisión” se utilicen como sinónimos, a fin de establecer las diferencias entre la terminología legal y la que utiliza von Wright, diremos que una omisión es un tipo especial de abstención que consiste en no hacer algo que se *debía* hacer. Este “deber” muchas veces se origina en una norma jurídica (prescripción) pero no siempre es así, tanto en el uso jurídico como en el uso vulgar, ya que también puede haber omisiones por incumplimiento de otras normas o reglas sociales (por ejemplo, uno puede decir “omití cerrar con llave el auto”, que es como reconocer que no se ha cumplido con alguna regla de prudencia).

La importancia de la distinción entre habilidad y capacidad reside en que en ocasiones ese deber alcanza exclusivamente a quienes tienen una habilidad y en otras también a los que tiene la capacidad para adquirirla. Así por ejemplo, para juzgar si ha existido responsabilidad por parte de un cirujano que omitió realizar cierta incisión sumamente difícil y de excepcional complejidad durante una operación muy delicada, será diferente la conclusión si se trata de un especialista reconocido que efectuó varias intervenciones similares con éxito que si es un médico a quien no se podía exigir una destreza sobresaliente. En este caso es la posesión de la habilidad la que permite establecer si ha habido omisión.

En cambio, siguiendo un ejemplo similar, si lo que no se hizo en la operación fue el cumplimiento de elementales reglas de asepsia, ningún médico podría excusarse diciendo “yo no sabía que eso era importante, así que como no poseo la habilidad no he realizado ninguna

³⁴ Douglas Price, Jorge; *Preliminares a la teoría de las normas*, General Roca, FADE, 1990, el subrayado me pertenece.

³⁵ *Ibid.*.

omisión”, pues en este caso lo que se exige es la capacidad genérica consistente en la posesión de los conocimientos mínimos que debe tener toda persona que ejerce la medicina.

3. ANALISIS DE LAS NORMAS PRESCRIPTIVAS, SUS ELEMENTOS Y CLASIFICACIONES

En el lenguaje cotidiano solemos hablar de “*análisis*” o de “analizar algo” cuando nos dedicamos a estudiar una cosa o una cuestión en profundidad, cualquiera sea el método que empleamos para hacerlo (así muchas veces decimos que “analizamos la situación antes de decidir” para significar que no hemos resuelto a la ligera). Sin embargo en el idioma técnico de muchas disciplinas (filosofía, derecho, sociología, química, física, etc.) “*suele entenderse muy frecuentemente hoy el análisis como la descomposición de un todo en sus partes. A veces se quiere indicar con ello una descomposición de un todo real en sus partes reales componentes, tal como ocurre en los análisis químicos. Pero casi siempre la descomposición en cuestión es entendida en un sentido lógico o mental. Se habla en este último caso de análisis de un concepto en tanto que investigación de los subconceptos con los cuales el concepto en cuestión ha sido construido, o de análisis de una proposición en tanto que investigación de los elementos que la componen*”³⁶.

En consecuencia, dedicarnos al “*análisis de las normas prescriptivas*”, como pide el programa de cátedra, quiere decir algo diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora: Significa *descomponer* (por así decir) el concepto, en sus partes integrantes o *elementos*.

Los conceptos de *análisis* y *elemento* son correlativos. Analizar algo es separarlo en sus componentes, que llamamos *elementos*. Identificar los elementos siempre es una tarea en relación a algo, un *todo*, que es objeto de *análisis*. La idea de *elemento* proviene de la filosofía antigua. Lo que caracterizó a los filósofos presocráticos fue la búsqueda de los elementos o entidades últimas que, a su entender, constituían la realidad y en particular la realidad material (este uso se conserva aún en química cuando se habla de la “tabla periódica de los elementos”). Por extensión analógica, más tarde el término se utilizó para referirse a los *últimos componentes* de algo (sea una cosa o un concepto) sometido a análisis. Es en este sentido que consideraremos a los elementos de las normas prescriptivas.

Dado que no hay acuerdo entre los filósofos de la ética o del derecho respecto a qué son las *normas*, tampoco podría haberlo en relación a cuales son sus elementos conceptuales. Para comenzar de algún modo nosotros seguiremos a von Wright³⁷, quien se ocupa de analizar las normas que son prescripciones (a las que no define sino que agrupa alrededor del ejemplar paradigmático que son las leyes del estado). Esto no significa que este sea el único análisis posible; ni siquiera es uno en el que haya consenso mayoritario (no hay ninguno con tal característica) y en general se trata de un desarrollo teórico desconocido por la mayoría de los

³⁶ Ferrater Mora, op. cit., voz “Análisis”.

³⁷ En *Norma y acción*, cap. V. Hay un preciso resumen del análisis de von Wright en Nino (op. cit., cap. II). Como esta ficha es complementaria y no sustitutiva de la bibliografía, aquí se realizará apenas una síntesis del tema, cuyo desarrollo concordante con el programa de la cátedra se encontrará en los textos mencionados.

operadores jurídicos (abogados, jueces, etc.) en su práctica cotidiana. Sin embargo constituye una propuesta sumamente clara y razonable que merece tomarse como punto de partida.

El desarrollo de este tema está claramente efectuado por ese autor y sintetizado con precisión por Nino, por lo que creo innecesario reiterar aquí dichos textos. Sólo voy a referir sintéticamente que von Wright agrupa los elementos en tres clases:

- El *núcleo normativo*, constituido por los elementos que las prescripciones tienen en común con otras normas (aunque von Wright no lo dice expresamente, se entiende que se refiere a otras normas *de acción*, ya que este núcleo no es la estructura lógica de las *reglas ideales*). Estos elementos son: 1º) carácter, 2º) contenido y 3º) condición de aplicación.
- Elementos que son *características específicas* de las prescripciones, que las distinguen de los otros tipos de normas: 4º) autoridad, 5º) sujeto y 6º) ocasión.
- Otros dos elementos “*pertenecen de una manera esencial a toda prescripción sin por ello ser ‘componentes’ de las prescripciones en el mismo sentido que los mencionados anteriormente*”³⁸. Estos son: 7º) promulgación y 8º) sanción. Es de hacer notar que el autor no aclara en qué sentido este último grupo de elementos difiere del anterior. Para Kelsen la sanción ocupa un lugar tan gravitante en el concepto de norma jurídica (que para él es lo mismo que prescripción) que es este componente el que la distingue de las otras normas.

En cuanto a la clasificación de las prescripciones, aclararé previamente que –como se verá a lo largo de toda la carrera- no puede hablarse de clasificaciones *correctas* o *incorrectas*. Clasificar consiste en agrupar ejemplares (trátese de personas, cosas o conceptos) en distintas clases según posean o no ciertos rasgos que para el caso se consideran relevantes. Elegir qué característica es relevante depende de los fines para los cuales querramos usar la clasificación. Por ejemplo, si lo que nos interesa es hacer un estudio electoral, puede convenir clasificar a los individuos según su domicilio electoral para ubicarlos en las distintas ciudades en que votan, independientemente de cual sea el lugar en donde efectivamente viven. Esta clasificación no tendrá ninguna importancia si el objetivo es determinar el consumo de energía eléctrica. En este caso tomaremos como unidad al “consumidor”, que puede ser un grupo familiar, una empresa o una dependencia estatal, y distinguiremos en grandes y pequeños usuarios según la cantidad de energía utilizada.

Hecha esta aclaración, con respecto a las prescripciones adoptaremos (por los motivos ya expresados) la clasificación que se sigue del desarrollo de von Wright. Tomando cada uno de los elementos se harán distinciones según cómo se manifiesten éstos en las normas. Como el sistema clasificatorio también se encuentra desarrollado en la bibliografía, me limitaré a señalar los rasgos generales, remitiendo al lector a dichos textos:

- Según el *carácter*, encontramos normas 1º) obligatorias, 2º) prohibitivas y 3º) permisivas.
- De acuerdo con el *contenido* (que está constituido por la acción), las normas pueden ser 1º) positivas (de “hacer” o de *comisión*) y 2º) negativas (abstenciones u omisiones).

³⁸ Von Wright (1963), pág. 87.

- Tomando la *condición de aplicación*, clasificamos a las normas en 1º) categóricas y 2º) hipotéticas.
- Según la *autoridad*, podríamos distinguir 1º) tomando en consideración el ser del que emanan y en tal caso clasificaríamos a las normas en a) teónomas y b) positivas; y 2º) de acuerdo a la coincidencia entre ese ser y el destinatario las dividiríamos en a) heterónomas y b) autónomas.
- Por el *sujeto normativo* se clasifican en 1º) particulares (éstas incluirían las llamadas por Kelsen *normas* individuales) y 2º) generales. Estas últimas a su vez pueden ser a) conjuntivamente generales y b) disyuntivamente generales.
- De acuerdo a la *ocasión* también pueden clasificarse las normas en particulares y generales y estas últimas en conjuntivas y disyuntivas, según las circunstancias de tiempo y lugar en que deba cumplirse el contenido de la prescripción. Von Wright llama “eminentemente generales” a las normas que son generales tanto respecto del sujeto como de la ocasión.
- Teniendo en cuenta la *promulgación* y la *sanción* von Wright no formula una clasificación de las prescripciones.

Apéndice: LOS LIMITES DE LA TEORIA DE LAS NORMAS

Hemos hecho un ligero recorrido señalando a qué nos referimos cuando hablamos de *normas*, alrededor de qué ejemplos conocidos podemos agruparlas, en qué sentido puede hablarse de su contenido de verdad, cómo se identifica la acción humana a la que aluden, cuales son sus componentes y de qué manera podemos clasificarlas. En la mayor parte de los casos nos hemos ocupado de un tipo particular de normas que llamamos *prescripciones*.

Sin embargo es necesario recordar que no se ha especificado qué lugar, en orden de importancia, ocupan las normas –y particularmente las prescripciones- en el derecho. Debe ponerse esto en claro ya que al enfocar nuestro estudio de esta manera podría parecer que se aceptan implícitamente las siguientes afirmaciones:

- Que el derecho es un conjunto de normas.
- Que éstas son normas prescriptivas.

Hay teorías expuestas con mucha profundidad y seriedad que sostienen estos puntos (claramente Kelsen), pero se trata de suposiciones sumamente problemáticas. Es posible construir un modelo coherente a partir de tales afirmaciones e integrar las observaciones empíricas de modo que encuentren siempre explicación en dicho modelo, sobre todo si los aspectos de la realidad que podrían controvertirlo se excluyen del derecho por tratarse de cuestiones de moral o de política a las que se califica como ajenas. Sin embargo esto no nos asegura una explicación satisfactoria del derecho, entendiéndolo por ello un panorama que nos permita comprender el mundo en que se mueven los operadores jurídicos, sus prácticas y sus reglas de argumentación. A lo más, este enfoque podría distinguir las prácticas “científicas” de las que no lo son (llamando “científicas” a las que coincidan con la teoría).

Según una vieja anécdota, los generales austríacos de fines del siglo XVIII y principios del XIX, mientras eran derrotados por Napoleón batalla tras batalla, afirmaban de él: “*gana, pero no es científico*”. Una teoría que condene del mismo modo las prácticas reales del derecho puede llegar a igual grado de irrelevante autosatisfacción. Este es el peligro de considerar que en la “teoría de las normas” se encuentra algo así como “la clave” del derecho. Aunque habitualmente los abogados operamos con normas como quien usa herramientas de trabajo y aunque la mayoría de esas normas son las que aquí hemos llamado *prescripciones*, este conjunto parece ser apenas la punta del iceberg que emerge de la superficie del agua, mientras las diez onceavas partes que la sostienen permanecen sumergidas y fuera de la vista.

Poner el acento excluyente en las prescripciones implica identificar fuertemente al derecho con el estado (tarea a la que se dedicó una tradición filosófica que encuentra su principal origen en Hobbes, teórico del estado moderno absoluto³⁹). Ello implica despreciar (cuando no excluir por “no jurídicos”) otros centros de producción de normas provenientes de la práctica social no estatal, como las costumbres, la moral o la política (entendida en un sentido amplio). Las consecuencias prácticas de esta visión consisten en que los grupos gobernantes se consideran autorizados a excluir o ilegalizar esas prácticas cuando éstas los afectan.

Además, establecer que el derecho se compone sólo de normas implica suponer que el lenguaje en que éstas se expresan mantiene una significación unívoca, homogénea e invariable, en la sociedad y en la historia, desconociendo cómo la atribución de sentido depende de espacios culturales más amplios y diversos y cómo ella traduce los conflictos que atraviesan la vida social. Decir que el derecho es un conjunto de normas puede ser acertado en contextos restringidos en donde se dan por supuestos una serie de acuerdos básicos fundamentales. En los demás casos, que son los de todos los días, el derecho más parece ser una práctica social en la que los grupos, clases e intereses sociales de diversa índole se expresan a través de argumentaciones normativas.

Junto con el ideal monolítico del estado moderno, la concepción del derecho como *ciencia* ha entrado en crisis⁴⁰ y la perspectiva de una visión única del derecho (la del soberano de Hobbes) se desplaza hacia un “pluralismo jurídico” que acepta el conflicto en la base de la producción normativa. La misma idea de *ciencia* como conocimiento neutral que reflejaba la realidad de modo cada vez más perfecto, idea que servía de modelo a aquella concepción del derecho, ha sido puesta seriamente en duda desde la década de 1960⁴¹.

De allí que los distintos aspectos y perspectivas de las normas que se han ido desarrollando en esta unidad no debieran asimilarse a las rigideces conceptuales con que se ha identificado la teoría de las normas en el pasado. Si antes se creía que “la norma jurídica” era

³⁹ Así todas las normas son dictadas por el soberano o autorizadas o consentidas por él. Hobbes, Thomas; *Leviatan* (1651), Madrid, Sarpe, T. I, Cap. XXVI.

⁴⁰ Ver Minda, Gary, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, New York, New York University, 1995 y Cárcova, Carlos M., *Teorías jurídicas alternativas. Escritos sobre derecho y política*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.

⁴¹ Entre muchos otros por Kuhn, Thomas, *La estructura de las revoluciones científicas* (1963), México, Fondo de Cultura Económica, 1995; Feyerabend, Paul, *Contra el método* (1970), Barcelona, Agostini-Planeta, 1993, y Polany, Michael, *Personal Knowledge* (1958), Chicago, The University of Chicago Press, 1974. Más recientemente Hacking, Ian; *Representar e intervenir* (1983), México, Paidós, 1996.

como el ladrillo del edificio del derecho, hoy podría concederse que conocer cómo está hecho el ladrillo no deja de ser importante, pero también debe tenerse en cuenta que hay otros materiales de construcción y que además no hay un solo edificio ni un único arquitecto ni estilo.

.....